



בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
צפורה פיגנבוים, מפקחת בכירה

תיק תביעה מס': 108/13

- בענין :**
1. מרים שרייבר וצור מרים
 2. קסנטיני איתן איריס
 3. משען מאיר ויהודית
 4. קליין דימונה ומשה

ע"י ב"כ עו"ד ד. ניסנבאום
מרח' אורן 25, ת.ד. 3700 חיפה 31036
טל': 04-8252747, פקס: 04-8252743

התובעים

נ ג ד

1. גנון שמעון
2. גנון רבקה

2. גילור יהושע
גילור רונית

ע"י ב"כ עו"ד א. בית הלחמי ו/או שמואל אלקלעי
מרח' אחד העם 5א', חיפה 31048
טל': 04-8626247, פקס: 04-8622577

הנתבעים

פ ס ק - ד י נ

7. שבע דירות מונה הבית המשותף נושא הדיון : דירה אחת בקומה ראשונה , שתי דירות בכל אחת מהדירות שניה ושלישית , ושתי דירות המשתרעות כל אחת על קומות רביעית וחמישית . בעלי שתי הדירות בקומה השלישית , הם הנתבעים כאן, מבקשים לבנות כל אחת לעצמה מרפסת זיזית ; מבין 5 הדירות האחרות מתנגדים לכך בעלים של 4 דירות – הם הנתבעים : בעלי שתי הדירות מתחת לדירות הנתבעים ובעלי שתי הדירות מעל דירות הנתבעים . רק בעלי הדירה בקומה הראשונה מסכימים לבניה . קיימתי ביקור במקום במעמד הצדדים ובאי כוחם ביום 16.1.14 והתרשמתי עד כמה היטיבה כב' השופטת למלשטרייך-לטר לתאר את המבנה בפסק הדין שנתנה ביום 7.5.13, ואין לי אלא לצטט את סעיפים 2.1-2.3 שלו:

"2.1 מדובר בבית משותף המצוי ברח' מרטין בובר 10 חיפה במקרקעין הידועים כגוש 11192 חלקה 190 [להלן: "הבית המשותף"]

2.2 בבית המשותף יש סה"כ 7 דירות, והוא מכיל טיפוס י דירות שונים...בבית הקרקע דירה אחת, ולה מוצמדת כל החצר הקדמית כגינה. בקומה השניה יש שתי יחידות דיור, שסובבת אותן בכוון החזית והצד מרפסת רחבה [כיוון צפון ומזרח ביחידה אחת וכיוון צפון ומערב ביחידה השניה] ומוצמדת להן חצר בעורף הבנין. בקומה השלישית שתי יחידות דיור, ללא מרפסות, וצמודה להן חצר גדולה בעורף הבנין. בקומה הרביעית שתי יחידות פנטהאוז המתפרש גם לקומה החמישית, וצמודה להם בחזית הקומה הרביעית מרפסת גדולה. כך נמכרו הדירות לדיירים השונים בנ. לכל אחד מהדיירים שביעית מהרכוש המשותף.

2.3 דיירי הקומה השלישית [הם המשיבים] בקשו להוסיף בחזית הבנין מרפסות קונסוליות [זיזיות] מפלדה, כל אחת בת 14 מ"ר, באופן שיבנו מעל מרפסות הקומה השניה [ששטח כל אחת מהן כ- 16 מ"ר] ויהיו למרפסות הקומה השניה מעין תקרה, מקום שלפי מבנה הבית המקורי מיקום "התקרה" הוא רק בקומה הרביעית".

2. טוענים התובעים בתביעה, כמו גם בסיכומי הטענות, כי יש להם הזכות לכך שתיאסר על הנתבעים הבניה המבוקשת על ידיהם, מנימוקים אלו:

(א) הנתבעים חסרים את הרוב מבין בעלי הדירות המהווה תנאי -בלתו-אין בחוק המקרקעין להרחבת הדירה;

(ב) הבניה מממשת זכויות בניה המהוות רכוש משותף תוך פגיעה בזכויות היחסיות העומדות לזכות התובעים;

(ג) לא הונחו בפני התובעים תוכניות בניה מגובשות כשהן נותנות מענה לאפשרות של פגיעה קונסטרוקטיבית במבנה, ברכוש המשותף לרבות היעדר פתרונות ניקוז, חיבור לבנין, פגיעה בחיפוי של הקיר החזיתי וכו';

(ד) הבניה תסב נזק לחזות הארכיטקטונית הייחודית של הבית;

(ה) המרפסות הזיזיות אם תיבניה תסבנה לדירות מתחתן פגיעה בדמות הפרעה לזרימת אוויר, לחדירת אור, וכן למטרדי רעש, המולה, ריחות צליה ועוד, כשם שהשימוש שהנתבעים עושים בחצרות המוצמדות לדירותיהם מסב מפגעים אלו כבר כיום.

3. הנתבעים דוחים את כל טענות התובעים על בסיס טיעונים אלו:

(א) הנתבעים מפליגים בשבחן של מרפסות;

(ב) הדין מאפשר כיום בנית מרפסות ולא מן הדין למנוע מהנתבעים יתרון זה בשם היעדר רוב קנייני של בעלי הדירות;

(ג) לכל אחת מדירות התובעים ישנו מרחב חיצוני לדירה גדול משמעותית מזה שעומד לרשות הנתבעים, מרחב הפונה לנוף, בדמות מרפסות גדולות. לנתבעים לעומת זאת יש רק חצר מוצמדת בעורף הבית 'כלואה' בין קירות תומכים ולא פתוחה אל הנוף.

(ד) נימוקי התובעים מופרכים קנטרניים מהווים שימוש לרעה בזכות ונגועים בחוסר תום לב קיצוני בעטיו נכון לשלול מהם הסעד מן הצדק לו הם עותרים.

(ה) בנית המרפסות לא מממשת זכויות בניה של דירות אחרות;

(ו) בנית המרפסות לא פוגעת ביציבות הבניין;

(ז) המרפסות המתוכננות תתרומנה לשלמות הארכיטקטונית של הבית.

(ח) אין במרפסות כדי לפגוע באף לא אחת מדירות התובעים הן מהטעם שחלקן מעל דירות הנתבעים וחלקן האחר – חזית המרפסות היא לכיוון צפון שהינו דל באור, ובאחת הדירות גם הותקנה פרגולה שנועדה להצל על המרפסות.

(ט) התובעים לא עמדו בתנאי ההוכחה של פגיעה מהותית המוגדרים בסעיף 71ג[ד] לחוק המקרקעין.

המסגרת הנורמטיבית

4. ברע"א 1462/10 אטיה נ' שגיא [מיום 2.8.2012] נתן ביהמ"ש העליון פרשנות רחבה למונח 'הרחבה' פרשנות שעולה בקנה אחד עם מטרת החקיקה המיוחדת אותה מבטא הפרק הדין במימוש זכויות בניה, ומגשימה את מטרותיו. וכך נפסק שם:

"כל שהמחוקק גילה לנו בשפת החוק הוא כי "הרחבה" מגדילה את שטח הרצפה של הדירה המורחבת".

חיזוק לדעה זו נמצא בע"א [י-ם] 1415/00 אברהם נ' אזרד [4.7.2001], הגם שניתן לפני פסק דין עטיה, ללמדנו שזו מגמת החקיקה משחר חקיקת הפרק הנ"ל בחוק המקרקעין:

"לא מצאנו בלשון החוק כל אינדיקציה לכך ש'הרחבה' נועדה לפתור רק בעיה של מצוקת דיור אמיתית. גם אין רמז לכך שהרחבה לא יכולה להתייחס לבניית מרפסת, שהרי כבר נפס שמרפסת היא חלק מדירה".

בית המשפט מתייחס באמירה זו לע"א 190/84 דיבון נ' הממונה על המירשם פ"ד תשמ"ה[2], 265.

מכאן שבנית מרפסת זיזית הינה בבחינת הרחבת דירה לגביה מתייחס הדין במסגרת הפרק הדין במימוש זכויות בניה, כחוק מיוחד.

5. החוק המיוחד, הלא הוא תיקון 18 לחוק המקרקעין שם סוף למבוי הסתום אליו הגיעו בעלי דירות ביוזמם תכניות להרחבת דירותיהם מקום שלא היתה הסכמה של כל בעלי הדירות. 'חיבוק הדב' הזה הסתיים עם חקיקת תיקון 18 לחוק המקרקעין. דא עקא שהתיקון לחוק לא פרץ את גבולות הצורך בהסכמת בעלי דירות עד כדי ביטול הצורך בהסכמה כלשהי, בחינת 'איש הישר בעיניו יעשה'; ממש לא. החוק קבע תנאים שבהתקיימם זכאים בעלי דירות להרחיב את דירותיהם; בהיעדר התקיימות התנאים – לא קמה הזכות לביצוע הרחבה. אביא דברים בשם אומרם מתוך פס"ד אטיה הנ"ל, תוך שהוא מפרש ומפשט את סעיף 71א] לחוק המקרקעין קובע פסק הדין כי:

"לפי סעיף זה [71א] – צ.פ., בתנאים מסוימים, זכאי בעל דירה לבנות על הרכוש המשותף לשם הרחבת דירתו, גם אם אין הסכמה לכך מצד כל בעלי הדירות, אלא רק מצד רוב מיוחד של בעלי הדירות".

פסק הדין מנתח את התכלית הכפולה של דבר חקיקה זה, התכלית האובייקטיבית והתכלית הסובייקטיבית ומגיע למסקנה כי:

"מדברים אלו אנו למדים כי המטרה שאותה ביקש המחוקק להגשים באמצעות דבר החקיקה הייתה להקל על מצוקת הדיור ולאפשר ניצול יעיל יותר של הקרקע על-ידי הרחבת הדירות. זאת באמצעות הפחתת כוחו של המיעוט, ונטילת "זכות הווטו" שלו באשר להחלטות הנוגעות לרכוש המשותף שעניינן הרחבת דירה (מיגל דויטש קניין כרך א 697-696 (1997) (להלן: דויטש-קניין); רע"א 11017/08 פל נ' ליבוביץ, פסקה 15 ([פורסם בנבו], 16.8.2010) (להלן: עניין פל)).

בעקבות הדרישה שבחוק להסכמת כלל בעלי הדירות לכל הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית (סעיף 62א) לחוק), היו בעלי דירות נתונים פעמים רבות לחסדיו של המיעוט, שלעיתים היה נוקט בעמדות לא ענייניות בתמורה למתן הסכמתו לשינויים המבוקשים. כך, במקרים רבים הוקפאו תכניות להרחבת דירה עקב דרישות מופרזות שהועמדו בתמורה להסכמה, או עקב צרות-עין לשמה (ראו: עניין פל, פסקה 15; השוו: ת"א (מחוזי ת"א) 45652/88 שטנג נ' מינצר, פ"מ התשנ"ה (4) 221, 230 (1995); ע"א (מחוזי חי') 2821/01 וילסקר נ' לויט, פסקה 8 ([פורסם בנבו], 8.8.2002)).

זוהי התפיסה הרעיונית שעמדה נגד ענינו של המחוקק במועד הליכי החקיקה. עם זאת, אין בדברי ההסבר התייחסות מפורשת למשמעות המונח "הרחבה".

והלאה משם -

התפישה היא שזכויות הקניין בבית המשותף עוצבו מלכתחילה באורח שונה מזה של זכות בעלות במובן ה"קלאסי" (שהוגדרה כזכותו של אדם לעשות ולא לעשות בקניינו כרצונו), כך שבעלי הדירות מוותרים על חלק מהאוטונומיה הקניינית הקנויה להם ומקנים חלק מזכויותיהם למסגרת

השיתופית המתמשכת והקבועה (עניין צודלר, בעמ' 562-564). דפוס זה מצר את תוכנה של זכות הקניין הנפרדת ברכוש המשותף כדי להתאימה לתכונות הייחודיות של הבית המשותף. כך, בנסיבות מסוימות ניתן להגביל את יכולתו של המיעוט לכפות את רצונו על הרוב, גם אם משמעות הדבר היא פגיעה בזכויותיו הקנייניות של המיעוט ברכוש המשותף ... כאמור, מטרת התיקון עניינה בהקלה על מצוקת הדיור וניצול עדיף ויעיל של הקרקע באמצעות הרחבת הדירות. זהו האינטרס הניצב אל מול זכות הקניין של המיעוט ברכוש המשותף". [ההדגשה שלי –צ.פ.]

בהתייחסו שם לטענה בדבר התקיימות תנאי חוק התכנון הבניה לרבות קיומו של היתר בניה קובע פסק הדין חד משמעית כי –

איני סבור כי שאלת היתר הבנייה – שנבחנת בעיניים "תכנוניות" ולא "קנייניות" – היא זו שתכריע את הכף.

6. פיתוח נוסף של הדין שצועד עקב בצד אגודל עם החק יקה החדשה קובע כי לא עוד שרירות בעלים. לא זכאי עוד בעלים להתנגד לבניה ברכוש המשותף בשם זכות הקניין שלו. נורמה משפטית זו נגזרת הן מסעיף 14 לחוק המקרקעין והן מהאיזונים הנגזרים מחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. לאחרונה ניתן בבית המשפט העליון פסק דין שמגבש ומסכם עקרון זה. רונות אלו. ראה ע"א 3511/13 שורצברגר נ' מרין ואח' מיום 24.7.14 שם מנתח כב' השופט דנציגר את הערכים שבבסיס חוק פינוי בינוי בזיקה להתנגדות המיעוט לשתף פעולה עם מיזם פינוי-בינוי, אולם העקרונות שם נכונים באנלוגיה גם לבית משותף שאינו אלא זעיר אנפין ל"מקבץ פינוי בינוי" כהגדרתו באותו חוק:

"ההסדר הקבוע בחוק פינוי ובינוי עולה בקנה אחד עם מעמדה החוקתי של זכות הקניין בשיטתנו, חרף פגיעתו בה... על פי הוראת חוק היסוד, הלכה היא כי אדם לא ינושל מרכושו וזכויותיו בו לא תפגענה אלא "לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש" ... יחד עם זאת אין משמעו של מעמדה החוקתי של זכות הקניין כי בכל מקרה בו ניצבת היא על כף המאזניים למול אינטרסים נוגדים נוטה הכף לכיוונה. אין היא זכות מוחלטת ולעיתים פגיעה בה תוכר כהכרחית..."

שתי גישות מתחרות ביחס למושג 'קניין' קנו להן שבת בפסיקתו של בית משפט זה... הראשונה, שבבסיסה חירות הקניין של הפרט, רואה בקניין מתחם של "שרירות בעלים" – משאב אשר לבעליו זכות סופית מוגנת מהתערבות חיצונית לקבוע את שייעשה בו וחופש נרחב לממשה כרצונו בהתאם לשיקול דעתו המוגבל רק מלבצע שימושים אסורים ... השניה, שבבסיסה תפיסה הרואה בקניין מוסד משפטי שנועד לשרת מטרות חברתיות שונות רואה בקניין "זכות מורכבת" שאינה אחידה מושגית... על פי גישה זו משמעותה המדויקת של זכות הקניין משתנה בהתאם לאינטרסים המתנגשים ולנסיבות העניין, כאשר במסגרתה יש ליתן משקל משמעותי לחירות הבעלים לנהוג בקניינו כרצונו אך גם לערכים נוספים וביניהם הגדלת הרווחה המצרפית, וכן החובות שמוצדק להטילם על בעל הקניין בתנאים מסוימים מכוח היותו חלק מן החברה וחבר בקהילה הנהנה מיתרונות חברות זו...

גישות אלה ממקמות באופן שונה את נקודת האיזון , כמו גם את אופן עריכתו, בין זכות הקניין לבין אינטרסים חברתיים וצורכי הציבור המתנגשים עימה...

אף לפי הגישה הראשונה, "שרירות בעלים" אינה מקימה לפרט זכות מוחלטת לעשות בקניינו שימוש מכל סוג שהוא ואין הוא נהנה מאוטונומיה בלתי מוגבלת בבואו להגן על קניינו..." [פסקאות 21-23 לפסק הדין].

7. מקום שהרוב מתנגד למימוש זכויות בניה על ידי האחר, חייבת ההתנגדות להיות כנה עניינית ותמת- לב, וחייבת הערכאה השיפוטית לבחון את נימוקי ההתנגדות לגופם כדי להתרשם שאכן כך הוא. ראה ע"א [חי'] 835/08 צבי נ' פרי ואח' ניתן ביום 18.11.2009 שקבע לאמור:

"השאלה שצריכה להישאל הינה , אם כן , האם, על דרך העיקרו , במקום שהבקשה להוצאה של חלקים מסוימים מן הרכוש המשותף והצמדתם לאחת מהדירות לא זכתה לרוב הדרוש בסעיף 7ב(א) לחוק, יש עדיין להידרש לשאלה האם התנגדותם של המתנגדים הינה תמת לב , והאם לא נתקיימו נסיבות בהן מן הראוי לכפות על המתנגדים את הסכמתם הר כגיגית.

בעניין זה דעתי הינה כי אכן סעיף 14 לחוק המקרקעין מקפל בתוכו את עיקרון החובה לנהוג בתום לב גם באשר להפעלת זכות הקניין.

בעניין זה ראוי להביא הדברים הבאים הלקוחים מפסק דינו של כבוד הנשיא ברק בפרשת רוקר : רע"א 6339/97 רוקר נגד סלומון , פ"ד נה (1), 199, בעמ' 279.

"תום הלב מניח כי בעל הזכות דואג להבטיח את זכותו , עם זאת תום הלב מבקש למנוע הפעלת הזכות מתוך התעלמות מקיומו של הצד האחר ובהתעלם מהאינטרס החברתי. אכן תום הלב קובע אמת מידה אובייקטיבית של התנהגות הוגנת של בעל זכות המבקש על רקע האינטרס החברתי הכולל להגשים את האינטרס העצמי תוך התחשבות באינטרס של הזולת עמדתי על כך באחת הפרשות בצייני: "עקרון תום הלב קובע רמת התנהגות של אנשים הדואגים כל אחד לאינטרס של עצמו. עיקרון תום הלב קובע כי השמירה על האינטרס העצמי צריכה להיות הוגנת ותוך התחשבות בציפיות מוצדקות ובהסתמכות ראויה של הצד האחר. אדם לאדם – לא זאב ולא מלאך ; אדם לאדם – אדם".

אף כי לא על נקלה יתערב בית המשפט ויטיל סייגים על דרך מימושה של זכות הקניין על ידי בעליה הרי ניתן לחשוב בהחלט על מצבים בהם עמידה על קוצו של יוד במימושה של הזכות תיחשב כבלתי הוגנת, ואפשר ובית המשפט יתערב בה".

8. הפסיקה גם קבעה על מי נטל הראייה להוכיח כי העמדה שמוצגת על ידי בעל דירה היא עמדה שעולה בקנה אחד עם מימוש זכויות במקרקעין בתום לב . ראה חוות דעתו של כב' השופט סוקול, שהיתה דעת הרוב, בעשא (חי') 13877-04-09

קיסרי נ' שלומוב ולפיה בעל הדירה המבקש לבנות עליו הנטל המשפטי לשכנע כי העמדה המתנגדת של בעלי הדירות האחרים לוקה בחוסר תום לב:

"מכח עיקרון תום הלב רשאי בית המשפט לבחון את זכויות הצדדים המתדיינים בפניו על פי אמות מידה אובייקטיביות . עם זאת בית המשפט אינו בוחן רק את נימוקיו ושיקוליו של המתנגד לבנייה, אלא עליו לבחון גם את התנהגותו ותום לבו של הבונה... זאת ועוד, נקודת המוצא לכל דיון בעניין בניה ברכוש משותף הנה כי לאף אחד מהשותפים אין זכות לשימוש ייחודי ברכוש המשותף. תפיסה של הרכוש המשותף לשימוש ייחודי ובנייה ברכוש המשותף, מחייבת קבלת הסכמתם של כל השותפים, ולמצער, הסכמת הרוב כנדרש על פי הוראות סעיף 71' לחוק המקרקעין, התשל"ט-1969. על המבקש לבנות ברכוש המשותף לפעול, בטרם התחלת הבנייה, לקבלת ההסכמה של כל הדיירים. לעיתים עליו לכנס אסיפת דיירים ולעיתים די שיפנה לשאר הדיירים בבית המשותף לקבלת הסכמתם. דייר המתחיל לבנות ללא פניה לשאר בעלי הבית פועל בחוסר תום לב. גם אם לא מושגת ההסכמה, משיקולים הנראים בעיני המבקש כפסולים, אל לו לעשות דין לעצמו ועליו לנקוט בהליך מתאים בבית המשפט או בפני המפקחת כדי לכפות את ההסכמה...

זאת ועוד, לגישת חברי על המתנגד לבנייה לשכנע כי עומדים לו נימוקים ענייניים וסבירים על פי מבחן אובייקטיבי. איני יודע מהם אותם נימוקים שיעמדו במבחן האובייקטיבי, ודומני כי התנגדותו של אדם לעשיית שימוש ייחודי ברכוש משותף תהא בדרך כלל התנגדות עניינית. אין כל מקום לכפות על אדם לוותר על קניינו רק בשל רצון של שכן לעשות שימוש ייחודי ברכוש המשותף. גם עמידתו של דייר על קבלת טובת הנאה כלשהי כתנאי למתן הסכמתו לוותר על זכויותיו, אפילו טובת הנאה כספית, אינה מהווה בהכרח חוסר תום לב. גם התנגדות בשל החשש לירידת ערך הדירה של המתנגד אינה חסרת תום לב.

אוסף כי ראוי שבית המשפט יזהר פן ישים עצמו במקומם של בעלי הדין. עיקרון תום הלב אינו נועד להעביר לבית המשפט את שיקול הדעת מתי להסכים לבנייה ברכוש משותף, אלא רק לאפשר לו למנוע התנגדות של שכן מנימוקים פסולים.

ובא פסק הדין בע נינים של אברהם נ' פדאל עש"א 17181-05-11 שדן בבקשת המשיבים שם, דיירים במבנה אחורי, לבנות מרפסת לדירתם, בקשה שאפילו גובתה בהיתר בניה כדין אלא ש- 3/4 מבעלי הדירות, שהיו דירות המבנה הקדמי, התנגדו לבניה בנימוק שזכותם לבניה דומה תיפגע. פסק בית המשפט כי:

"לענין הטענה כי תייווצר מעין זכות וטו לדיירים בבנין הקדמי בנוגע לכל בניה שיתבקשו הדיירים לבצע בבנין האחורי [בהיותם הרוב – פ.צ.] יש להשיב כי על רוכשי הדירות במבנה האחורי [אלו שחפצו בבניה – פ.צ.] היה לקחת נתון זה בחשבון בעת הרכישה, ובכל מקרה, בדעת רוב [השופטים ש' וסדרקרוג והשופט ר' שפירא] אם אכן תהיה ההתנגדות סתמית או נוגדת עקרונות שיטת המשפט, הסמכות של ביהמ"ש לבדוק את ההתנגדות עומדת בעינה אך אינה יכולה לבוא במקום הדיירים אלא על דרך בחינה נדרשת".

כב' השופטת וסרקרוג הרחיבה בחוות דעת נפרדת לאמור:

"גם הגישה הסוברת – על פי דעתי – כי יש למפקחת סמכות לברר את נימוקי ההתנגדות, אין בית המשפט צריך לשים עצמו במקומם של בעלי הדין ולענין זה מפנה אני לדברים שנאמרו ע"י כב' השופט סוקול בעש"א 13877-04-09 [קיסרי נ' שלומוב –צ.פ.].

ראשית יש להזכיר כי בפס"ד צבי על אף שעקרונית הצטרפתי לדעתו של כב' השופט זרנקין לפיה יש סמכות למפקחת לבחון נימוקי ההתנגדות הרי משיושם העיקרון האמור ונבחן על פי הנימוקים שפורטו באותו מקרה, הצטרפתי לתוצאה עליה הצביע כבוד השופט יצחק כהן. שנית, ראוי להבחין היטב בין עצם השאלה אם בעל דין המתנגד לבקשת שכנו לבנות ברכוש המשותף יכול לבוא לבית המשפט ולומר 'מתנגד אני' ללא הוספת כל נימוק ודי בכך כדי למנוע הבניה, ולמעשה לצמצם או למנוע את סמכותו של בית המשפט או של המפקחת לדרוש פירוט נימוקי ההתנגדות, לבין היקף יישום סמכותו של בית המשפט לבקר את הנימוקים שהועלו.

בשאלה הראשונה שהיא העקרונית, אם לאור האמור בסעיף 71 לחוק המקרקעין שכותרתו "שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבניה" עומדת הזכות למתנגד שלא לפרט את נימוקיו להתנגדות, אפילו אלה סתמיים ואפילו נוגדים הם את עקרונות שיטת המשפט ותום הלב – שהוא אחד מעקרונות היסוד של השיטה – סבורה הייתי וסבורה אני שאין לאפשר התנגדות ללא הנמקה. בשלב השני, שלאחר הבאת הנימוקים, סמכותו של ביהמ"ש לבוא ולבחון נימוקים אלה היא מצומצמת ביותר [הדגשה שלי – צ.פ.].

אכן אין לאפשר לדעתי להתנגדות סתמית שאינה עניינית או שיש בה משום שימוש לרעה בזכות הקניין כך נאמרו על ידי בפס"ד צבי והוספתי שם כדוגמא כאשר בעלים של מספר דירות בבניין מתנגדים מתוך כוונת קנטור או בשל "מוצא או נסיבות אחרות הנוגדות את עקרונות שיטת המשפט ואשר אין בהם דבר או חצי דבר עם הפגיעה בזכות הקניינית כשלעצמה." [ההדגשה במקור – צ.פ.]. לא כך היו פני הדברים במקרה דנן.

9. רוב אריתמטי לעומת רוב מהותי של בעלי דירות – סוגיה זו נשזרת בסוגית שלילת 'שרירות הבעלים'. מחד גיסא התיקונים התחיקתיים בחוק המקרקעין נועדו לשים קץ לכוח המוגזם שנותר בידי מיעוט מתנגד כל אימת שאותו מיעוט תקע יתד בגלגלי האפשרות לממש זכויות בניה. מנגד השתמר לכאורה הכוח המשפטי של שלטון הרוב אותו הוא יכול להפעיל ברודנות כלפי המיעוט. למציאות אפשרית זו התייחס כב' השופט רובינשטיין ברע"א 9626/05 נציגות הבית המשותף מרחוב הרב עמיאל 7 ת"א נ' יעקב ומיכל אבימור [מיום 16.11.05] ופסק לאמור:

"אימוץ הגישה של שלטון הרוב (ע"א 810/82 הנזכר בעמ' 737) אינו מובן מאליו. עד חקיקתו של חוק המקרקעין משנת 1969 נקט המשפט הישראלי בעמדה לפיה לכל שותף זכות וטו, ואין המיעוט כפוף לרוב (ע"א 393/58 ברוינר נ' לברון פ"ד יד(1)169; ו' ויסמן חוק המקרקעין תשכ"ט-1969 מגמות והשיגים ירושלים תש"ל, 45). התפיסה ששררה היתה כי "בשותפות ברכוש כל

אחד מהשותפים הרי הוא בבחינת זר לגבי חלקו של האחר "(סעיף 1075 למג'לה).

ביסוד השינוי שהביא בכנפיו חוק המקרקעין עמד הרצון להקל על ניצולו היעיל של הנכס, גם בהעדר הסכמה בין הבעלים (י' ויסמן דיני קניין בעלות ושיתוף סעיף 5.61 ענ' 217). ברם אין מגמה זו יכולה לשמש את הרוב כדי לעשות שימוש במעמדו באופן העלול לקפח את זכויות המיעוט. סכסוך שכנים כשאי תרע מזלם של שכנים ואינם חיים בשלום עלול למרר חייהם של כל הנוגעים בדבר. החלופה היא כמובן ניסיון להתגבר על יחסים גרועים ולקבע גדרי "דעלך סני לחברך לא תעביד" "מה שעליך שנוא לחברך לא תעשה" כדברי התנא הלל במסכת שבת ל"א, א' ("א')

...ברור הוא כי רוב ומיעוט יש לבדוק לא רק 'אריתמטית' אלא גם מהותית".

דיון

01. יישום ההלכות שנסקרו לעיל מביא אותי למסקנה כי דין התביעה להתקבל. אלה נימוקי החלטתי:

(א) התובעים מהווים רוב בעלי הדירות

- התובעים המתנגדים לבניית המרפסות הזיזיות מהווים רוב בעלי הדירות. הנתבעים מהווים המיעוט שמבקש לכפות את רצונו על הרוב.
- שלא כדעתו של ב"כ התובעים, הרוב המתנגד לא חייב להוכיח פגיעה מהותית שעלולה הבניה המתוכננת להסב לו. חובתו היא אך זו: לבסס את התנגדותו בשיקולים ענייניים ותמי לב.
- על הנתבעים, שהם המיעוט, היה להרים את נטל השכנוע לכך ששיקולי התובעים נטולי תום לב; הם לא הרימו נטל זה – ולא בכדי. נימוקי ההתנגדות של התובעים הם נימוקים לגיטימיים, לא פוגעים בעקרונות שיטת המשפט הישראלי, ומשכך לערכאה שיפוטית אין סמכות להעדיף את היעדר זכויותיהם של הנתבעים על פני זכויותיהם של התובעים, או – אם תרצה – את צרכיהם של הנתבעים על פני צרכיהם של התובעים.
- ועוד, כל תובע ונימוקיו שלו, מה ששולל את הטענה של ב"כ הנתבעים בדבר 'בלוק חוסס', כאילו קיים רוב אריתמטי שמצדיק ב חנינת עמדות התובעים כולם כעמדה של בעלים אחד.

(ב) נימוקי התובעים מס' 3 [בהתבסס על עדות תובע מס' 3] –

– תובעים אלו מוצאים במבנה הארכיטקטוני הנוכחי של הבית איזון ראוי של מרחבי השימוש החוץ- דירתיים: "יש חלק מרפסות וחלק גינות וזה מאפשר הפרדה ואיכות חיים לשני הצדדים בצורה מאוזנת מבחינת רעש והסתכלות. זה עלול להשתנות בצורה דרסטית ברגע שתיבניה מרפסות נוספות. לנו דיירי הדירות העלינות יהיה כפל רעש וכפל הפרעה " עמ' 4 שו' 15-18. אותה עמדה הובעה בחקירה הנגדית : "זה [הבניה המתוכננת – צ.פ.] פוגע לטעמנו בצורה החיצונית של הבנין. עלול לפגוע מבחינת השקט. אנו היום כשיש מפגשים בגינות של השכנים [הנתבעים – צ.פ.] אנו או עולים קומה או יושבים בסלון איפה שזה יותר מרוחק. עלול להיות כפר של שימושים במקומות בעקבות אורחים לא יהיה לנו לאן לברוח..." וגו' – עמ' 7 שו' 13-16.

– התובעים הללו גם מוצאים יתר ון ארכיטקטוני בעיצוב הבית כמו שהוא, עיצוב שלא זו בלבד שלא שינה את פניו מאז הבית נבנה בשנות ה-90, אלא גם כל בעלי הדירות לרבות הנתבעים רכשו דירותיהם על בסיס עיצוב זה. ובלשון התובע מס' 3: "עצם הבנין שבנוי בצורה ארכיטקטונית מסוימת מרפסת בולטת מרפסות למטה הוא מצא חן בעינינו כשבאנו לקנות...המרפסות תשנינה את אופי הבנין וזה שינוי שלא נראה לנו " – עמ' 4 שו' 20-21. התובעים חזרו על עמדתם בעמ' 6 שו' 33: "עמדנו לקנות ברח' אחר, ולא קנינו והעדפנו את הבניה הזאת כי ראינו שהבניין יפה איך שהוא מוגש, התכנית של הבנין".

– התובעים מוסיפים חשש מהפגיעה באריחים הייחודיים המחפים את הקיר החיצוני של הבית אשר עלולים להיפגע ולא יימצאו אריחים זהים לתיקון, חשש שאינו עוד בעלמא לאחר שכבר נשרו בעבר אריחי חיפוי והדיירים התקשו למצוא אריחים זהים, וגם לנוכח העדויות מצד אנשי המקצוע של הנתבעים.

– נימוק ה תנגדות נוסף שהעלו תובעים אלו הוא חשש מהשלכות המרפסות שתיבניה על ידי הנתבעים, ככל שתותרנה, על יציבות המרפסת שלהם שהיא מרפסת תלויה בקומה מעל, בשטח גדול בהרבה.

– התובעים הללו גם מציינים את ההתנהגות הכוחנית של הנתבעים כלפיהם לנוכח עמדותיהם אלו שהתבטאה ב "רעש מכון, רדיו חזק, והיו כמה פעולות שלא הסכימו לשלם מסים לתקופה מסוימת. והפרעות לא קטנות. גם זה הפחיד אותנו" עמ' 5 שו' 29-31 לפרו'.

– תובעים אלו היו מוכנים לאפשר לנתבעים בנית מרפסות חלופיות קטנות יותר תוך נסיגה מחלק מנימוקי ההתנגדות שלהם, ואף הציעו זאת לנתבעים, אך נדחו.

– לדעתי כל אחד מנימוקי התובעים הללו ה וא לגיטימי כן ענייני ומובע בתום לב.

(ג) נימוקי תובעת מס' 1 [בהתבסס על עדותה] -

– תובעת זו היא בעלת דירה בקומה מתחת לאיזו מדירות הנתבעים ; המרפסת החזיתית של דירתה היא מרפסת פתוחה נטולת גג . מחפה עליה המרפסת של דירות התוב עים 3-4 שנמצאת שתי קומות מעל [מעל 5 מ']. אם תיבנינה המרפסות של הנתבעים תהפוך המרפסת שלה , כמו גם של שכנתה באותה הקומה התובעת מס' 2 – למרפסת מקורה.

– לתובעת זו, כעדותה בעמ' 9 שו' 28: "ניסיון החיים עם ה שכנים הוא גרוע. לפי דעתי התנהלותם תמיד לא היתה טובה . בייחוד השכנים שמעלי [הם נתבעים מס' 1 – צ.פ.] במיוחד כשבאו עם הדרישה לבנית המרפסת הם נקטו באמצעים כוחניים מילוליים ולחץ שאוותר".

– כבר כיום, העידה התובעת הזו, פוגעים בפרטיות שלה "הם מציצים לי לתוך הדירה . בימי שבת הראש הוא איום ... שכנים אלימים מילולית ופיזית . השכנה גנון עמדה לפני הדירה שלי עם איזה פרח וצעקה 'את זבל' והאדון מלמעלה צעק 'את זבל' וזה נמשך איזה שלוש שעות ... זה הסגנון" עמ' 10 שו' 4-8, ללמדנו על עומק חוסר האמון שרוחשת תובעת זו לנתבעים, שהניע אותה לפי עדותה גם להגיש נגדם תלונה במשטרה.

– את הרצון לשמר את החזות הארכיטקטונית של הבית כמו שהוא מונה התובעת כאחד מהשיקולים, והעלתה אותו רק בחקירה הנגדית.

– בכל זאת היתה נכונה להציע הצעה חלופית שנדחתה על ידי הנתבעים.

(ד) נימוקי התובעים מס' 4 [לפי עדות תובע מס' 4] -

– העד העדיף רכישת דירה עליונה בבית זה על פני דירה בבית הסמוך אותו מציגים הנתבעים כשלמות ארכיטקטונית לאחר שהוספו בו מרפסות זיזיות, חרף האפשרות שעמדה לו, כי העדיף את יתרונות המבנה הזה שחלקם הוא דווקא היעדר מרפסת מתחת למרפסת הדירה שלו [הוא אחת משתי הדירות העליונות].

– גם תובע זה הצביע על חוסר האמון כלפי הנתבעים בעטייה של הבקשה לבנייה מטעמם, ובלשונו: "הצורה שבה היא הוגשה ומה שבא בעקבותיה" – עמ' 12 שו' 34.

(ה) נימוקי התובעת מס' 2 – [בהתבסס על עדותה]

– דירתה משיקה לדירת תובעת מס' 1 ומתחת לדירת נתבעים מס' 2. היינו בחזית דירתה מרפסת פתוחה . את התנגדותה היא תולה בצורך להבטיח כניסת אור ואויר לסלון.

– במהלך שנות מגוריה בבניין היא סבלה מרעש שעלה מדירות הנתבעים וזאת בהיעדר מרפסת; היא חרדה מהתגברות הרעש אם תהיה מרפסת.

– הנתבעים גם נוהגים בה לא בכבוד ומקללים אותה בשל התנגדותה למרפסת.

– היא חוששת מתוצאות של בניה לא חזקה דיה בקומה מעליה.

– התובעת נאותה אף היא להתפשר על בנית מרפסת קטנה יותר ובלבד שתבנה על עמודים, מחשש להתמוטטות.

77. כחוט השני עובר בעמדות התובעים הרצון לשמר את החזות הארכיטקטונית הנוכחית של הבנין. נימוק זה הוא נימוק לגיטימי שהוכר ככזה לא רק בחוק אלא גם בפסיקה. ראה סעיף 2 [א] לתקנון המצוי שמ גריר פגיעה ברכוש המשותף "לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה". וגם ראה חוות דעתו של כב' השופט כהן בפסה"ד בענין נטלה צבי וכן פסקה 19 לפסה"ד בענין עש"א (חי') 22123-10-10 מיום 14.3.11. טיעון זה אינו נסוג מפני דעתו המקצועית של העד מטעם הנתבעים, האדריכל אלי ניסן שמצא פגמים ארכיטקטוניים במבנה כמו שהוא. החזות הארכיטקטונית היא עניינם של בעלי הדירות, ואף לא אחד מהם לא הסמיך את הנתבעים "לתקן משגים" תכנוניים של הבנין.

27. הוא הדין לגבי ההשלכות של חיפוי מעל מרפסת פתוחה : לא כמות האור והאוויר שיימנעו או יוגבלו בשעה כזו או אחרת ביום כזה או אחר בשנה הם שעומדים על הכף אלא הפיכת מרפסת פתוחה למרפסת מקורה חרף התנגדות בעליה. זכותן של התובעות מס' 1-2 קמה להן לא רק מכוח סעיף 2[א] לתקנון המצוי אלא גם מכוח סעיף 2[ב] לו.

37. הוסף לכך את סימני השאלה הביצועיים שעולים מעדויותיהם של אנשי המקצוע האחרים שהעידו מטעם הנתבעים, ואין עוד – לנוכח הנימוקים דלעיל – צורך להרחיב בהם.

47. הגם שמצאתי כנות ותום לב מבוססים דיים בהתנגדות התובעים ליוזמת הבניה של הנתבעים, פטור בלא כלום אי אפשר ואתייחס לנימוקים שהעלו הנתבעים עצמם:

(א) את הבניה הם מתרצים ברצון להגדיל את מרחב המגורים שלהם לכיוון מערב, כיוון הנוף. כשלעצמו הרצון אינו פסול, אולם מימושו כפוף להתקיימות תנאי הדין.

(ב) תמוה שהנתבעים לא הקדימו קיומה של אסיפה כללית של בעלי הדירות לצורך דיון בתכניתם. דווקא בבית בו כמות הדירות לא גדולה, ועל רקע יחסי שכנות תקינים בעבר – כך לפי עדויות מקצת העדים – היה מקום ליידע את השכנים לא על דרך של הודעות מעם הועדה המקומית. הדרך בה בחרו הנתבעים

רק העצימה את החשדנות וחוסר האמון, נימוקי התנגדות לגיטימיים כשלעצמם. כב' השופט סוקול רואה דווקא בהתנהגות זו משום חוסר תום לב. ראה פס"ד קיסרי הנ"ל.

(ג) הנתבעים מתנגדים לחלופות שהועלו אגב בירור ההליך אשר היה בהן – מבחינת התובעים – איזון בין העמדות. נימוקיהם מושתתים על הצורך לשנות את העיצוב הפנימי של דירותיהם כדי להתאימו לחלופות אלו. ותמהני על שום מה יועדפו צרכי הנתבעים על פני צרכי התובעים.

51. מכל הנימוקים דלעיל דין התביעה להתקבל. אני אוסרת על הנתבעים בניית המרפסות הזיזיות לפי הבקשה להיתר התלויה ועומדת כיום לדיון בפני רשויות התכנון.

61. אשר להוצאות משפט:

(א) אין לי ספק שניהול ההליך הסב הוצאה כספית משמעותית לכל הצדדים.

(ב) יחד עם זאת כדי לא להעצים את המתחים הבינאישיים שקיימים כבר כיום ראיתי להעמיד את ההוצאות על סכומים נמוכים מכפי אלו בהם כרוך ניהול ההליך.

(ג) כל אחד מזוגות הנתבעים ישלם לתובעים כולם, באמצעות באת כוחם, הוצאות ושכ"ט כולל מע"מ בסך של 5,000 ₪. הסכום ישולם בתוך 45 יום מהיום שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה [24.4.13] ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום י"ז/אב/תשע"ד 13/08/2014
העתיקים יישלחו לב"כ הצדדים.

צפורה פיגנבויס

מפקחת בכירה על רישום מקרקעין